



Corte D'Appello di Milano

Sezione Quarta Civile

composta dai Magistrati:

Maria Rosa Busacca

Presidente

Anna Mantovani

Consigliere Relatore

Francesco Distefano

Consigliere

nella causa civile iscritta al n. r.vg. **593/2022** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), elettivamente domiciliato in VIA VOLTA, 77 22100 COMO presso lo studio dell'avv. FRANZINI MARCO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. BASSI ANDREA (*C.F._1*) PIAZZA DEL POPOLO, 14 22100 COMO;

RECLAMANTE

CONTRO

Controparte_1

[...] (C.F. *P.IVA_2*), elettivamente domiciliato in VIA BIANCHI GIOVINI, 3 22100 COMO presso lo studio dell'avv. AULETTA ANDREA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

RECLAMATO

E

Controparte_2

Controparte_3

NESPOLI

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI COMO

PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 29/09/2022,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il presente procedimento ha ad oggetto il reclamo avverso il decreto di omologazione ex art. 177 e 180 L.F. del Tribunale ordinario di Como, pubblicato in data 01.06.2022, con il quale è stato omologato il concordato preventivo proposto da *Controparte_1* [...] e in c.p. (di seguito solo *CP_1* , rubricato al n. 13/2020.

Il reclamante impugna il provvedimento di omologa, deducendo:

1. Che il Tribunale ingiustamente lo avrebbe escluso dal voto quale creditore di *Cont* sulla scorta di un supposto conflitto d'interessi tra il votante e la massa creditoria. Poiché *Pt_1* era un creditore dissenziente, in quanto il suo voto sarebbe stato negativo, se fosse stato computato ai fini del raggiungimento delle maggioranze previste, il concordato non sarebbe stato approvato.

Ha in primo luogo contestato che sia ammissibile un'esclusione per conflitto di interessi nel caso di concordato preventivo. In particolare, ha dedotto che non potrebbero trovare applicazione, per il caso concreto, i principi affermati in materia di conflitto d'interessi dalle Sezioni Unite in un'ipotesi di concordato fallimentare (e non preventivo), e richiamati nel decreto reclamato, poiché in quel caso si trattava di stabilire se ad una società collegata al creditore proponente domanda di concordato sarebbe spettato o meno il diritto di voto.

In ogni caso, ha pure escluso per il caso di specie l'esistenza degli estremi su cui poter fondare un'ipotesi di conflitto, in quanto *Pt_1* non sarebbe portatrice di interessi coincidenti con quelli del debitore, essendo solo questa l'evenienza che avrebbe semmai potuto inficiare il voto.

2. Con il secondo motivo, reclama inoltre il decreto di omologazione in quanto ritiene che, come già dedotto in sede di omologa, il concordato dovrebbe ritenersi difettante della fattibilità giuridica.

Si è costituita la società **CP_1** in concordato, che ha anzitutto ribadito la configurabilità del conflitto di interessi per il quale **Pt_1** è stata esclusa dal voto.

Ha poi soggiunto che la stessa avrebbe comunque dovuto essere esclusa dal voto in quanto non vanterebbe alcun credito nei confronti della **Cont** alla data di udienza ex art 174 l.f. (28.6.2021), in ragione di partite e contropartite esistenti in quel momento tra le parti, come altresì attestato dal Commissario Giudiziale nella sua costituzione ex art. 180, co. 2, l.f., all'esito della verifica contabile.

1) Conflitto di interessi

Quanto al primo profilo di censura, in via di fatto è pacifico che **Pt_1** sia ad un tempo creditrice e debitrice della **CP_1** ancorché per entrambe le posizioni pendano giudizi in cui tali qualità sono contestate (da **Pt_1** quanto al suo essere debitrice, da **Cont** quanto alla qualità di creditore di **Pt_1**).

In particolare, **Pt_1** è debitrice di **Cont** in quanto le parti avevano sottoscritto, in data 27.05.2019, un “Contratto di Associazione in Partecipazione” (doc. 31), con il quale l'odierna reclamata si impegnava ad apportare alla **Pt_1** la propria esperienza e tecnologia (“Know How”), nonché il marchio **Cont** dietro l'obbligo di **Pt_1** (associante) di garantire all'associata il diritto di partecipare agli utili derivanti dalla attività di **Pt_1** stessa, nella misura del 25% dell'utile netto di bilancio. **Pt_1**, dunque, in base a tale contratto, è obbligata a corrispondere a **CP_1** il 25% degli utili, fino al 2029. In relazione a tale contratto **Pt_1** ha promosso giudizio (prima che venisse depositata la domanda di concordato) per ottenere la risoluzione dello stesso per impossibilità sopravvenuta ex art. 1463 c.c., deducendo che **Controparte_1** non svolge più alcuna attività e dunque il contratto non può avere esecuzione.

Pt_1, poi, si dichiara creditrice, sulla base di un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di fatture relative alla fornitura di beni e servizi, decreto opposto da **Cont** la quale nel giudizio di opposizione contesta la sussistenza del credito.

Occorre evidenziare che il concordato oggetto di esame, a sua volta, consente ai creditori di soddisfarsi in quanto l'attivo verrà alimentato principalmente con i crediti che matureranno nei confronti di **Parte_1** in forza del suddetto contratto di associazione in partecipazione fino

all'esercizio 2029. Ne deriva che il debito della reclamante costituisce la principale posta attiva portata da ^{Cont} quale modalità di soddisfacimento dei creditori sociali.

Il Tribunale, in sede di valutazione circa l'ammissione al voto, ha disposto l'esclusione del creditore ^{Pt_1}, in quanto in posizione di conflitto di interessi. Invero, muovendo dai principi espressi da Cass. SSUU 17186/18, secondo cui il divieto di voto va esteso anche ai casi non espressamente disciplinati dalla legge, qualora sia ravvisabile un conflitto d'interessi, il Collegio ha ritenuto ^{Pt_1} portatrice di un interesse in conflitto, laddove il suo voto negativo, peraltro determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze ex art. 177 l.f., avrebbe in definitiva consentito alla società di non corrispondere il credito derivante dal contratto di associazione in partecipazione di cui è titolare ^{Cont}. Nello specifico, ha ritenuto che tale evenienza, di fatto ostativa per l'approvazione del piano da parte del ceto creditorio, avrebbe comportato il fallimento della società e, di conseguenza, lo scioglimento del contratto di associazione in partecipazione, da cui derivano proprio le liquidità destinate al pagamento della massa.

In sostanza, alla luce di tale ricostruzione, ^{Pt_1} non avrebbe votato a favore del piano in quanto perseguito un proprio specifico interesse, quello cioè di far dichiarare il fallimento di ^{CP_1} e, conseguentemente, di vedere risolto il contratto da cui deriva l'obbligo di pagamento nei suoi confronti, in danno alla massa creditoria.

Nel proprio reclamo ^{Pt_1} censura la ricostruzione fatta dal Tribunale, in quanto afferma che in realtà il conflitto di interesse che può essere ritenuto rilevante è solo quello che contrappone un creditore agli altri creditori, sovrapponendo il proprio interesse a quello del debitore in concordato. Nel caso di specie, invece, il prospettato conflitto contrapporrebbe il creditore ^{Pt_1} al debitore stesso, e dunque sarebbe manifestazione di un conflitto che è in qualche modo immanente alle procedure concorsuali, dove l'interesse del debitore ad esdebitarsi con il minore onere possibile si contrappone all'interesse del creditore a vedersi soddisfatto nella misura maggiore possibile. Nel caso in esame si sarebbe quindi al di fuori dalle ipotesi di cui si è occupata la Suprema Corte, e sulle quali si è attestata la giurisprudenza quando ha ravvisato ipotesi di conflitto che comportino l'esclusione dal voto.

^{Pt_1} inoltre censura la pronuncia del Tribunale per aver ritenuto la sussistenza di un suo interesse alla dichiarazione di fallimento di ^{Cont} al fine di sottrarsi al pagamento dei debiti derivanti dal contratto di associazione in partecipazione, affermando che con il fallimento tale contratto si scioglierebbe automaticamente. Per contro, a detta della reclamante, ciò sarebbe erroneo perché

l'art. 77 l.f. prevede lo scioglimento del contratto quando vi è il fallimento dell'associante, e non quello dell'associato, come sarebbe nel caso di specie.

Ritiene questa Corte che il motivo di reclamo debba essere disatteso, in quanto deve confermarsi la sussistenza di un conflitto di interessi rilevante ai fini dell'esclusione dal voto.

Invero, deve premettersi che è corretta la deduzione della reclamante in ordine al fatto che la natura del conflitto a cui deve aversi riguardo sia afferente ad una contrapposizione di interessi tra il creditore (che deve esprimere il voto) e gli altri creditori. Queste sono le ipotesi di cui si è occupata la giurisprudenza, la quale, se pure ha espresso una nozione ampia di conflitto, ravvisando lo stesso in tutte le ipotesi in cui *“l'interesse individuale confligga con l'interesse comune della collettività”*, in ogni caso ha mantenuto la contrapposizione tra l'interesse del singolo e quella degli altri creditori, e non mai ha tratteggiato tale interesse rilevante quale quello che pone in conflitto il creditore *versus* debitore.

Occorre allora analizzare il caso concreto, al fine di verificare se tale prevalenza di un interesse individuale del creditore ai danni degli altri creditori sia sussistente nella posizione di **Pt_1**.

Per inquadrare correttamente i fatti, si rileva che, se è vero che – diversamente da quanto affermato nel provvedimento di omologa - il fallimento di **Cont** non porterà automaticamente allo scioglimento del contratto di associazione in partecipazione, in ragione del fatto che l'art. 77 l.f. prevede lo scioglimento del contratto solo nel caso di fallimento dell'associante e non dell'associato, in ogni caso la sorte di quel contratto è comunque destinata ad esaurirsi, una volta che l'attività di **Cont** cessi con la dichiarazione di fallimento. **Cont** infatti, col fallimento, cesserà l'attività e dunque non potrà in alcun modo svolgere le controprestazioni previste nel contratto. Il fallimento, quindi, apre necessariamente la strada all'accertamento della risoluzione per impossibilità sopravvenuta, già predicata ed azionata da **Pt_1** al fine di svincolarsi dal contratto in essere. Inoltre, la clausola n. 6 del contratto di associazione, prevede che in caso di mutamento anche parziale della compagine societaria dell'associato, l'associante si riserva la facoltà di rescissione del contratto. Sicuramente, il fallimento comporta un mutamento della compagine societaria, e dunque consente a **Pt_1** di esercitare il proprio diritto potestativo di rescindere il contratto.

In questo quadro, non può negarsi che il voto contrario di **Pt_1**, che porterebbe, se computato, alla non approvazione del concordato e dunque alla dichiarazione di fallimento, concretizzi in primo luogo una contrapposizione tra creditore e debitore, in quanto **Pt_1** ha interesse al fallimento di **Cont** al fine di svincolarsi definitivamente dal contratto di associazione in partecipazione, al fine di

non dovere più corrispondere quella quota di utili a cui si è obbligata fino al 2029. E se ci si limitasse a questo rilievo, il conflitto non potrebbe essere ritenuto rilevante. Ma, come sopra espresso, il fatto che il contratto di associazione in partecipazione non abbia più effetto in conseguenza del fallimento di ^{Con} comporta anche che si configuri un conflitto tra il creditore ^{Pt_1} (nella sua veste anche di debitore di ^{Cont} e la massa dei creditori, che sono in tal modo costretti a subire gli effetti dello scioglimento del contratto, con conseguente contrazione dell'attivo diretto a soddisfare i loro crediti.

In altri termini, deve ritenersi che si profili proprio quel conflitto che inquina l'espressione di volontà del creditore che vota, in quanto egli ha sicuramente interesse, prima ancora che a vedere soddisfatto il proprio credito (rispetto al quale tra l'altro, in concreto, si prospetta ben poca possibilità di un soddisfacimento, dato la contestazione della sua sussistenza e della sua entità svolta da ^{Cont} e, comunque, dato lo stato di decozione di ^{Cont} stessa), e dunque prima ancora che a far valere la propria posizione di creditore di ^{Cont} a vanificare la sua posizione di debitore di ^{Cont} e ciò sia in danno di ^{Cont} stessa, ma soprattutto – una volta apertosi il concorso - in danno della massa dei creditori.

Appare prospettarsi, in questa espressione di voto contrario all'approvazione del concordato, una sorta di modalità abusiva di esercizio della pretesa di ^{Pt_1} di ottenere la risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, ovvero la sua rescissione, cercando di portare la situazione di ^{Cont} a quell'esito che renda inevitabile perdita di efficacia dello stesso già invocata in altra sede.

Per tali ragioni deve confermarsi l'esclusione dal voto di ^{Pt_1} per la presenza di un conflitto di interessi.

2) La fattibilità del concordato.

Se dunque devono ritenersi fermi gli esiti della votazione come valutati dal Tribunale, non vi è necessità di effettuare valutazioni in ordine alla sussistenza o meno del credito di ^{Pt_1}, dato che la sua posizione di creditore non è stata computata ai fini dell'esito della votazione. In sostanza, ai fini dell'approvazione del concordato, il credito di ^{Pt_1} resta estraneo e non è stato valutato.

Resta allora da valutare l'altro motivo di reclamo prospettato da ^{Pt_1}, e cioè quello relativo alla fattibilità del concordato stesso.

Quanto al secondo profilo di censura, relativo cioè alla presunta assenza dei presupposti di fattibilità giuridica del piano, ^{Pt_1} deduce:

I. l'irragionevole durata del piano, laddove la proposta concordataria è strettamente connessa alla durata del contratto di associazione in partecipazione, il quale verrà in scadenza decorsi dieci anni dalla proposizione della domanda di concordato (anno 2030);

II. la mancata verifica da parte del Commissario giudiziale dell'esistenza di garanzie personali rilasciate in favore di due istituti bancari, con la conseguenza che l'eventuale riscontro avrebbe dovuto imporre la formazione di una classe autonoma per il ceto bancario, al fine ultimo di scongiurare il rischio di conflitti d'interesse in seno al medesimo ceto. Con le classi sarebbe stata diverso anche l'esito della votazione, dovendosi raggiungere anche l'approvazione da parte delle classi;

III. la mancata verifica della solvibilità del garante e l'assoluta incertezza rappresentata dall'ipoteca volontaria che lo stesso prometteva di costituire a seguito di omologazione del piano. Quest'ultimo infatti prevede che un socio garante sia tenuto a pagare €30.000,00 l'anno, ove il credito annuale vantato da ^{Cont} nei confronti di *Pt_1* non raggiungesse tale importo. A garanzia della prestazione, lo stesso socio si impegnavo a costituire ipoteca. A questo punto *Pt_1* non solo ritiene che la garanzia non avrebbe potuto offrire sicurezza che il garante fosse all'occorrenza in grado di sopperire con immediatezza al fabbisogno finanziario del concordato; ma, inoltre, che non sarebbero neanche state chiarite le modalità di accensione dell'ipoteca stessa, né tantomeno i modi di escussione, per l'ipotesi in cui il socio garante non avesse disposto della liquidità necessaria.

Dal canto suo, la società ^{Cont}

I. ribadisce la ragionevolezza della durata del piano, che non può che rispettare le tempistiche previste da contratto e, dunque, la sua naturale scadenza successiva alla approvazione del bilancio 2029; né potrebbe chiedersi a *Pt_1* di pagare prima qualcosa la cui quantificazione è rimessa ad avvenimenti futuri (gli utili conseguiti per ogni esercizio);

II. ritiene insuscettibile di sindacato la decisione del debitore proponente di non suddividere i creditori in classi, laddove la legge non prevede l'obbligatorietà, bensì la mera facoltatività, del concordato con classi;

III. infine, evidenzia che la verifica della solvibilità dei garanti attiene alla sfera della convenienza economica del concordato, e, in quanto tale, è insindacabile dal giudice. Per altro verso, il piano, nella parte in cui prevede che il socio garante paghi € 30.000,00 l'anno, ove il credito annuale vantato da ^{Cont} nei confronti di *Pt_1* non raggiunga tale importo, risulterebbe perfettamente attuabile sotto il profilo giuridico.

La pronuncia del Tribunale su tale aspetto si è limitata ad affermare che non si tratti di questioni su cui vi debba essere una valutazione in sede di omologa, dato che si tratterebbe di questioni attinenti la fattibilità economica e perciò riservate al sindacato dei creditori.

Ritiene la Corte che anche tale motivo di reclamo debba essere disatteso.

Il tribunale si è limitato a concludere che le censure sollevate sarebbero attinenti alla sola fattibilità economica. Occorre peraltro meglio specificare in che termini tale conclusione sia condivisibile, dovendosi comunque pervenire alla conclusione che non vi sono gli estremi per dichiarare insussistente la fattibilità del concordato, in base a quei parametri valutativi che la giurisprudenza assegna al giudizio di omologa.

In primo luogo, si rileva che non viene mossa alcuna censura alla correttezza dei dati riportati dall'attestatore, ed in ogni caso la relazione (all. B.d di parte ^{Cont}) appare svolta in modo puntuale e riportante le precise verifiche contabili, e pertanto deve ritenersi attendibile. La criticità della relazione dell'attestatore invero, condurrebbe ad una valutazione anche di non fattibilità giuridica, dato che mancherebbero i presupposti perché anche la volontà dei creditori si sia espressa su dati attendibili. Ma questo non è il caso.

I punti critici peraltro sono essenzialmente quelli relativi alla riscuotibilità del credito nei confronti di ^{Pt_1} , che costituisce la posta più rilevante della massa attiva, e, attesa la possibile criticità di tale riscossione, la presenza di idonee garanzie nel caso in cui tale credito non venga riscosso, nella misura attesa.

Non appare rilevante, ai fini della valutazione della fattibilità giuridica, la questione relativa ai tempi di esecuzione del concordato, in quanto si tratta di aspetto che pertiene alle valutazioni di convenienza più che di fattibilità, e come tali insindacabili da parte del tribunale, in sede di omologa, e della Corte in sede di reclamo.

Anche la questione relativa alla riscuotibilità del credito in realtà non si configura come una valutazione di fattibilità giuridica, dato che il contratto è in essere e il credito di ^{Con} deve ritenersi sussistente, almeno allo stato degli atti. La possibilità che in concreto tale debito venga pagato o meno, attengono ad una valutazione di credibilità della fattibilità economica della proposta concordataria, che non può essere più di tanto presa in considerazione, se non sotto il profilo per cui, a fronte di tale plausibile criticità, la tenuta del concordato debba essere assistita da idonee garanzie.

Ed è quindi in ordine alle garanzie prestate che deve incentrarsi la valutazione in ordine alla fattibilità.

Su tale aspetto la reclamante deduce che le garanzie prestate non siano idonee, in quanto non adeguatamente precisate, e inoltre incerte in ordine alla liquidità del garante **CP_1** socio amministratore di **Cont** che si è impegnato personalmente a corrispondere fino all'importo di € 30.000,00 annui nel caso in cui l'importo corrisposto da **Pt_1** quale percentuale sugli utili non raggiunga tale soglia.

Su tale aspetto non può non rilevarsi come risulti formalizzato l'impegno di **CP_1** di prestare fideiussione per l'importo indicato nella proposta, a copertura della differenza tra quanto ipotizzato nel piano come credito nei confronti di **Pt_1** e quanto effettivamente riscosso. Risulta altresì formalizzato l'impegno dello stesso di rilasciare fideiussione assistita da ipoteca da iscriversi su un bene di sua proprietà, il cui valore di stima, come accertato dall'attestatore, è superiore al credito garantito.

Tale impegno può ritenersi sufficiente a coprire le eventuali mancanze dell'attivo, come ipotizzate in proposta, in quanto delle due l'una: o l'impegno viene rispettato, e allora il concordato potrà avere regolare esecuzione. Oppure non viene rispettato, cioè lo **CP_1** non rilascia la fideiussione promessa dopo la definitività dell'omologa e non iscrive ipoteca, e allora il concordato non potrà che essere risolto, in quanto il proponente si rende inadempiente alle obbligazioni di cui alla proposta.

Ma la possibilità che il concordato venga risolto perché alcuni degli impegni prospettati non si realizzano è insito in ogni proposta concordataria. Non è possibile effettuare una valutazione di non fattibilità del piano semplicemente ipotizzando, *ex ante*, che tali obbligazioni non verranno adempiute. Il giudizio di fattibilità deve attestarsi sul fatto che la proposta, se correttamente adempiuta, sarà idonea a soddisfare la massa dei creditori nella misura promessa. Tale valutazione ad oggi deve avere un riscontro positivo, in quanto la massa attiva appare sufficiente, e le garanzie promesse, se ritualmente prestate, sono da ritenersi idonee ad assicurare la corretta esecuzione del concordato.

A diversa valutazione dovrebbe giungersi se non vi fosse alcuna garanzia, o se la garanzia come prospettata si palesasse del tutto inadeguata. Ma ciò non può essere ravvisato nel caso di specie, in quanto la promessa di una garanzia assistita da ipoteca sufficientemente capiente configura come fattibile la proposta concordataria approvata dai creditori.

Conclusivamente, pertanto, il reclamo deve essere rigettato.

Il rigetto del reclamo consente di ritenere assorbito il reclamo incidentale subordinato svolto da CP_1 [...] in concordato.

La parte reclamante deve essere condannata alla rifusione alla reclamata delle spese del presente giudizio, secondo la liquidazione di cui in dispositivo.

PQM

La Corte di Appello, sul reclamo proposto avverso il decreto di omologa del concordato [...] Controparte_1, del Tribunale di Como di data 1/06/2022, così decide:

- Rigetta il reclamo;
- Condanna Parte_1 alla rifusione in favore di CP_1 in concordato delle spese del presente procedimento, liquidate in complessivi € 2.500,00 oltre rimborso forfetario spese generali, Iva e c.n.p.a.

Milano, 29/09/2022

Il Consigliere relatore

Anna Mantovani

Il Presidente

Maria Rosa Busacca